



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheiro-Substituto Márcio Martins de Camargo

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão: **21/08/2024**

Exame Prévio de Edital – **Julgamento**

M-002

TC-014754.989.24-2 e 015315.989.24-4

Representantes:

Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva – Sinaenco / Dias & Cardozo Engenharia Ltda.

Representado:

Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo - CINDESP

Responsável:

José Adalto Borini (Presidente)

Assunto:

Representações em face do edital do Pregão Eletrônico nº 002/2024, Processo Administrativo nº 005/2024, visando ao registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas, além de estudos e orçamentos para a boa execução de obras de edificações públicas e históricas, saneamento e infraestrutura urbana, elaboração de estudos e planos ambientais, também especialista em gerenciamento, fiscalização e apoio técnico/administrativo e laboratorial de obras, das mais diversas áreas de interesse dos municípios consorciados.

Advogados (cadastrados no e-TCESP): Gabriel Costa Pinheiro Chagas (OAB/SP Nº 305.149).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS, ESTUDOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E APOIO. INDEVIDA ADOÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA PREGÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MENOR PREÇO E DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA INDEVIDOS. FRAGILIDADE NAS JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ANULAÇÃO DO CERTAME.

Relatório

Tratam os autos de representações formuladas pelo **Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva – Sinaenco e Dias & Cardozo Engenharia Ltda.**, em face do edital do **Pregão Eletrônico nº 002/2024**, instaurado pelo **Consórcio Público Intermunicipal de Inovação**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

e Desenvolvimento do Estado de São Paulo - Cindesp, objetivando o “registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas, além de estudos e orçamentos para a boa execução de obras de edificações públicas e históricas, saneamento e infraestrutura urbana, elaboração de estudos e planos ambientais, também especialista em gerenciamento, fiscalização e apoio técnico/administrativo e laboratorial de obras, das mais diversas áreas de interesse dos municípios consorciados”.

Segundo o representante **Sinaenco**, o objeto posto em disputa se enquadraria na definição de “serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual” a que aludem as alíneas “a”, “d” e “h” do inciso XVIII do artigo 6º da Lei Federal n.º 14.133/2021¹, inviabilizando a (i) adoção da modalidade licitatória **Pregão**, consoante expressa vedação do artigo 29 da Lei nº 14.133/21². Reportando-se ao preconizado pelo artigo 37, § 2º da NLLC³, também teceu críticas ao (ii) critério de **julgamento por menor preço**, notadamente diante do montante previsto para a contratação (R\$ 184.828.289,10);

¹ Art. 6º - XVIII - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;

(...)

d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;

(...)

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso;

² Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

³ Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por:

(...)

§ 2º Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas “a”, “d” e “h” do inciso XVIII do caput do art. 6º desta Lei cujo valor estimado da contratação seja superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o julgamento será por:

I - melhor técnica; ou

II - técnica e preço, na proporção de 70% (setenta por cento)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

enquanto a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 85 daquela Lei⁴ tornaria (iii) indevida a utilização do **sistema de registro de preços**. Na sequência, discorreu sobre a natureza multidisciplinar dos serviços, que vão da elaboração de projetos à fiscalização de obras, inclusive com um amplo leque de requisitos de qualificação técnica, recomendando, ao menos, a (iv) participação de **consórcios** (vedada pelo artigo 3.2.11 do edital). Por fim, em se tratando da elaboração de estudos e projetos inseridos no conceito de engenharia consultiva, insurgiu-se contra o (v) **BDI** fixado no edital, que “*ao utilizar as diretrizes do acórdão 2622/2013*”, não se atentou ao fato de que aquelas “*dizem respeito a contratos de execução de obras públicas, com custos e metodologias distintas*”.

Antes de apreciar o pedido de sustação cautelar, o **Cindesp** foi convocado para o exercício do contraditório. Na mesma oportunidade, considerando a alteração promovida no critério de julgamento (para menor preço global) e a confusa motivação constante do ETP (Anexo I) para o não parcelamento da contratação, solicitou-se à Origem que (vi) justificasse a aglutinação dos serviços em lote único; bem como (vii) comprovasse o atendimento ao disposto no artigo 67, § 1º, da Lei 14.133/2025⁵, uma vez que foram acrescidas novas parcelas de relevância ao já extenso rol do item 9.4, b, do edital.

Após a apresentação de esclarecimentos por parte do interessado (ev. 22 do TC-14754.989.24), sobreveio representação de **Dias & Cardozo Engenharia Ltda**, cujas insurgências foram divididas nos seguintes tópicos: (vii)

⁴ Art. 85. A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

⁵ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

(...)

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

da modalidade de licitação inadequada; **(viii)** do mecanismo de contratação inadequado - SRP; **(ix)** da ilegalidade da exigência de tempo mínimo de experiência para comprovação da capacidade técnica; e **(x)** da necessidade de adequação do critério de adjudicação do objeto.

A sessão de abertura das propostas estava prevista para ocorrer no dia 18/07/2024; e diante de indícios da ocorrência de falhas na fase preparatória do certame **a matéria foi recebida pelo Egrégio Plenário na via do Exame Prévio de Edital.**

Expedida nova notificação, o Consórcio apresentou justificativas adicionais, acompanhadas de cópia do edital.

Assessoria Técnica, por sua vertente especializada em **Engenharia**, reputou parcialmente procedente a representação tratada no TC-14754.989.24 e procedente aquela constante do TC-15315.989.24, ambas com recomendações. Acolheu, ainda, as questões levantadas de ofício pelo Relator, propondo a realização de ampla revisão no edital do CINDESP.

Diversas não foram as conclusões de **Chefia de ATJ** e do **Ministério Público de Contas** que, em acréscimo, pugnaram pela anulação do certame em virtude da existência de vício insanável.

É o breve relato.

lac



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Voto

TC-014754.989.24-2

TC-015315.989.24-4

Os elementos colhidos durante a instrução conduzem ao reconhecimento da inviabilidade de prosseguimento do certame nos moldes concebidos pelo Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo.

(i e vii) Princípio pela indevida utilização do Pregão, hipótese que sustentou a ordem cautelar de paralisação do certame e que restou confirmada através da percuente análise empreendida pelo segmento especializado de ATJ. Com efeito, objeto posto em disputa extrapola o conceito de “*serviços comuns de engenharia*” (artigo 6º, inciso XXI, “a”, da Lei 14.133/2021), tornando inaplicável a adoção daquela modalidade licitatória, consoante expressa vedação do artigo 29 da Lei nº 14.133/21. Acolho, neste ponto, a íntegra da manifestação do órgão técnico, “*in verbis*”:

“Portanto, para que seja possível a licitação de serviços de engenharia por pregão é preciso que sejam enquadrados como serviços comuns e que tenham padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no edital.

O TR informa os produtos esperados na contratação, que serão demandados por ordens de serviço.

O Termo informa que, na data de emissão da OS, haverá reunião entre as partes para “informações gerais sobre o escopo do trabalho do empreendimento e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a serem adotados no planejamento, desenvolvimento e aprovação dos projetos e serviços” (item 8.1 do TR).

O TR também afirma que “Serão fornecidos ao CONTRATADO todos os documentos necessários e específicos para a elaboração de cada um dos estudos e projetos.” (g.n.).

Portanto, a nosso ver, resta claro não haver a padronização aventada pelo CINDESP. Cada produto será desenvolvido a partir de diferentes parâmetros e dados de entrada, estabelecidos depois de assinada a Ata, por cada um dos 41 municípios integrantes do consórcio. Os resultados produzidos dependerão destes dados de entrada e também da experiência, especialização e qualificação dos profissionais envolvidos na produção.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

No mais, a descrição dos produtos no TR demonstra haver produtos que não são padronizáveis e que dependem de situações locais que podem torná-los mais ou menos complexos.

A título de exemplo, o item 8.4.1 do TR apresenta condições que devem ser consideradas pelo projetista no levantamento de dados e que variam de local para local e que irão impactar diretamente a solução técnica adotada, o prazo para elaboração dos projetos, sua qualidade e seu custo.

Observamos que o custo de alguns produtos não contou com preço unitário específico na planilha de serviços. Constam os preços de mão de obra de alguns profissionais especializados e preços unitários de alguns serviços, que irão compor um preço final dos projetos, estudos e planos, a cada contratação e para cada produto almejado pela prefeitura contratante, demonstrando não haver padronização.

Outro exemplo de serviços que não contam com padronização são os estudos de viabilidade, descritos no item 8.4.2 do TR, que incluem análise comparativa de alternativas e eleição da melhor opção.

Outros exemplos de serviços que não podem ser enquadrados no conceito de serviços comuns de engenharia seguem ao longo do TR, como diversos estudos (geológicos, hidrológicos, ambientais (EIA e RIMA), laudos estruturais, etc.), projetos (pavimentação e restauração de pavimento, desapropriação, obras de arte especiais, abastecimento de água, esgotamento sanitário, barragens, iluminação, de restauro de bens tombados, etc.), laudos e pareceres e planos diversos (recuperação de áreas degradadas, encerramento e recuperação de área de disposição final de resíduos sólidos - incluindo aterros, planos diretores, planos de saneamento básico, de mobilidade, etc.).

Concluimos que, por haver no escopo diversos serviços técnicos especializados de engenharia de natureza predominantemente intelectual que não podem ser enquadrados como comuns, é vedada a utilização do Pregão, por conta do disposto no art. 29 da Lei”.

(ii) Igualmente imprópria, à luz do que dispõe o artigo 37, § 2º da NLLC, é a **adoção do critério de julgamento por menor preço**, uma vez que o objeto contempla as atividades previstas nas alíneas “a”, “d” e “h” do inciso XVIII do artigo 6º daquela Lei e o valor estimado da contratação supera os R\$ 300.000,00 (R\$ 184.828.289,10).

(iii e viii) Procedem, ainda, as críticas relacionadas à **adoção do sistema registro de preços**, cuja escolha restou comprometida pela ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 85 da Lei Federal n.º 14.133/2021, conforme destacado por ATJ:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

“O art. 85 é claro ao exigir a existência de “projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional”, para a contratação de obras e serviços de engenharia pelo SRP, o que não se verifica no presente objeto.

O TR descreve a necessidade de diversas atividades, já exemplificadas no item 1 deste parecer, incluindo projetos, estudos e instrumentos de planejamento municipal (planos) que deverão ser desenvolvidos conforme a necessidade de cada município contratante e que não podem ser considerados padronizados.

O CINDESP é composto por 41 municípios, com diferentes realidades e necessidades.

Outro indicativo que demonstra ser impossível a padronização exigida em Lei, é o fato que alguns dos produtos previstos no TR, como planos e estudos, não possuem preço unitário próprio na planilha de preços.

A planilha padroniza preços unitários de profissionais e serviços, num total de cerca de R\$184 milhões, mas o dimensionamento exato de quanto é necessário para a elaboração de cada produto do contrato é relegado a um momento pós licitação, inobservando o princípio do planejamento e podendo prejudicar a economicidade. É preocupante não haver definição clara de como serão definidos tais quantitativos e como será o controle de tais preços.

No mais, observamos que o ETP não apresenta uma ampla pesquisa de mercado que demonstre aptidão de diversas licitantes para atender às exigências de um edital com escopo tão amplo.

Tal pesquisa é pressuposto obrigatório para a utilização do SRP, conforme inciso I, §5º do art. 82.

Do exposto, consideramos procedente a reclamação”.

(vii e ix) A despeito das aludidas impropriedades, **que comprometem toda a estrutura do procedimento licitatório**, considero oportuno, como forma de bem orientar a eventual elaboração de um novo edital, alertar a Origem para a necessidade da promoção de ampla revisão dos



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

requisitos de qualificação técnica, nos termos preceituados pela instrução⁶ e ⁷, uma vez que constatadas falhas que vão desde a excessiva e injustificada definição das parcelas de maior relevância, contrariando o disposto no art. 67, §

⁶ ATJ-Eng:

“Como visto, a resposta do CINDESP não justificou tecnicamente as exigências relativas à qualificação técnica e, analisando o disposto no item 9.4 do edital, entendemos que demandam ampla revisão para adequação ao que dispõe a Lei 14.133/21.

A começar da redação do item 9.4.'b' que exige atestados em nome do licitante, mas que devem comprovar a qualificação profissional. O edital deve ser retificado para definir a qual tipo de qualificação o item se refere: operacional (da empresa licitante) ou do profissional. Também devem ser revistas as numerações dos itens subsequentes, conforme a qualificação a que se refiram.

O subitem 'b.1' exige informações que podem não constar no corpo dos atestados das empresas/profissionais, como a modalidade da contratação, número de processo e endereço do contratado, com potencial restritivo desarrazoado e que excede o disposto no art. 67.

O subitem 'b.2' elenca uma quantidade de parcelas tidas como de maior relevância e de valor significativo que contempla diferentes áreas da engenharia (edificações, infraestrutura, obras de patrimônio histórico, saneamento), diferentes atividades (estudos, inventários, projetos, planos municipais, minuta de lei, realização de controle tecnológico, projetos em BIM, fiscalização, gerenciamento, etc.) e diferentes especialidades da engenharia (engenheiro civil, mecânico, elétrico, agrimensor, sanitário, ambiental, florestal, geógrafo, geólogo, arquiteto, etc.), num rol extremamente extenso de atividades e que, muitas vezes, se refere a parcelas bastante específicas.

Somadas às atividades elencadas para comprovação da qualificação operacional, listadas no subitem 'b.3', tem-se uma quantidade de exigências que consideramos descabida e injustificada.

(...)

Existem diversas exigências de projetos desenvolvidos em BIM, sem a descrição no TR sobre os níveis de detalhamento exigidos, requisitos de dados para compartilhamento de informações, critérios específicos de medição e pagamento, exigência de entrega de produtos em formato neutro, etc. , o que pode tornar inócua a exigência de comprovação de qualificação técnica frente os produtos que serão recebidos.

Vale dizer que o ETP não justifica a necessidade de todas essas exigências. Tampouco foi apresentado qualquer documento técnico que o faça.

Ainda que seja permitida a participação de empresas reunidas em consórcios, entendemos que a competitividade está comprometida pela quantidade e especificidade das atividades exigidas na qualificação técnica tanto profissional quanto operacional. As parcelas eleitas para qualificação técnica devem se limitar dentro do escopo do contrato, aos serviços mais relevantes tecnicamente.

Outros itens da qualificação também apresentam falhas. O item 9.4.'c' exige comprovação de vínculo dos profissionais ainda na etapa de habilitação, superando o que dispõe no art. 67

(...)

A questão do momento da comprovação do vínculo dos profissionais exigidos também se repete em outros subitens do item 9.4, como o subitem 'e', e devem ser revistas. Ressaltamos ainda que a exigência de que o profissional conste na certidão de registro e quitação da empresa (pessoa jurídica) desatende ao que dispõe a Súmula 25.

Por fim, há ainda as exigências elencadas nos itens 'i' e 'j' que excedem o disposto no art. 67 e não retratam qualificação técnica para a execução dos serviços.

Do exposto, nossa conclusão é pela necessidade de revisão completa das exigências de qualificação técnica do edital, incluindo exigências que foram parcialmente repetidas no item 9 do TR (Anexo II do edital). Aliás, cabe também recomendação para que tais exigências sejam uniformizadas no edital e no TR.

⁷ ATJ-Eng:

“O art. 67 da Lei 14.133/21 estabelece os documentos aptos a comprovar a qualificação técnica profissional e operacional.

O inciso III do mesmo artigo possibilita a exigência de indicação do pessoal técnico, contendo “a qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos”, sem qualquer alusão a tempo de experiência dos profissionais.

O §3º, citado pelo representante, indica a possibilidade de aferição de experiência prática dos profissionais na qualificação, mas “salvo na contratação de obras e serviços de engenharia”, portanto excluindo tais atividades. Além disso, há a necessidade de previsão em regulamento sobre quais as provas alternativas aceitáveis. Portanto trata-se de caso inaplicável à presente contratação”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

1º, da Lei 14.133/2021, à exigência de tempo mínimo de experiência para comprovação da capacidade dos profissionais, em descompasso com o inciso III e §3º do mesmo artigo.

(vi e x) Deverá o Consórcio, ainda, reavaliar a necessidade de parcelamento do objeto, em atendimento ao previsto no inciso VIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21, notadamente diante das inconsistentes justificativas apresentadas, da extensa gama de produtos previstos no TR e das diferentes especialidades da engenharia e arquitetura envolvidas⁸.

(iv e v) Afasto, por fim, as irresignações direcionadas à vedação da participação de consórcios e ao BDI fixado no edital, aspectos que restaram solvidos no decorrer da instrução, nos termos sintetizados pelo *Parquet*, sem prejuízo das recomendações consignadas em seu parecer:

“Na visão ministerial, apenas dois tópicos devem ser julgados improcedentes, quais sejam os questionamentos da Representante Sinaenco acerca da vedação da participação de consórcios e do BDI fixado no edital.

Quanto ao primeiro tópico, nota-se que a versão retificada do edital apresentada pela CINDESP (Evento 53) já conta com a exclusão da proibição impugnada, tornando a crítica improcedente. Entretanto, ao edital deve ser incluído o disposto no § 1º do artigo 15 da Lei n.º 14.133/2021, em relação à qualificação econômico-financeira, nos termos do precedente tratado no eTC 11126.989.24, bem resgatado pela ATJ Engenharia.

8

ATJ-Eng:

“A resposta dada pelo CINDESP não justifica o modelo de contratação adotado.

(...)

O argumento de que não se trata de itens divisíveis não procede, tendo em vista a extensa gama de produtos previstos no TR e diferentes especialidades da engenharia e arquitetura envolvidas.

A informação de que o critério de adjudicação seria por “projetos pedagógicos” também não é clara e não guarda relação com o contido no edital, portanto não restou comprovado que o ETP foi elaborado de forma completa e adequada.

A justificativa do CINDESP de que se trata de produtos correlacionados e sequenciados não se aplica à totalidade dos objetos. Enquanto aceitável para um anteprojeto e um projeto básico, por exemplo, não é aceitável para o desenvolvimento de um plano de saneamento e de um acompanhamento técnico de obra, por exemplo, ambas atividades previstas no escopo da contratação.

Vale dizer que não estamos concluindo sobre a adequação ou não do parcelamento do objeto, já que esta conclusão cabe à Administração. Apenas estamos registrando que a questão não parece ter sido devidamente considerada pelo CINDESP, a partir das informações apresentadas nos autos.

A reclamação é procedente no sentido da necessidade de avaliação do CINDESP sobre a possibilidade ou não de parcelamento, registrando no processo administrativo do contrato sólidas justificativas técnicas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Quanto ao segundo tópico, não há que se falar em fixação de BDI pelo edital. Como bem detalhado pelo setor especializado desta Casa, o valor disposto no orçamento se encontra aceitável quando comparado com a tabela de referência, permitindo, ainda, o edital, que cada licitante informe sua taxa de BDI, adaptando-a a sua realidade. Improcedente, portanto, a insurgência, cabendo recomendação para atualização do orçamento nos termos da mais recente tabela referencial e para que o edital exija o detalhamento da proposta de preços, conforme definido no §5º do artigo 56 da Lei de Licitações”.

Diante do exposto, meu voto acompanha a instrução e considera **parcialmente procedentes** as insurgências, determinando, em face à gravidade dos óbices verificados, com reflexos sobre toda a estrutura do edital, que o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo promova a **ANULAÇÃO** do certame.

Acolhido tal entendimento pelo Plenário deste e. Tribunal, devem ser intimados Representante e Representada, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, archive-se.

É como voto.